

1509084-93.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

A droga apreendida com o réu é indubitosa, não só pela confissão como também pela prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo dela e do numerário com o tráfico, convencem que era mesmo para o uso próprio, ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1509084-93.2020.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509084-93.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3040096/2020 - PLANTÃO - 01 DP

AMERICANA, 11562764 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL BATISTA FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RAFAEL BATISTA FARIA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 25 de maio de 2020, por volta de 20 horas, na Rua Ema, 166, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 31 de março de 2021 (fls. 66), o réu foi citado (fls. 93).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 98/99).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena (fls. 129/131).

A Defesa, nos memoriais, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, princípio da insignificância. A quantidade da droga seria ínfima. Tratava-se de usuário de drogas (crack), sob o efeito de bebida alcoólica. Alegava existência de

circunstâncias que excluiria o crime e isentava o réu de pena. Para o caso de condenação, que fosse observada a confissão espontânea, atenuante, com isenção de dias-multa e custas processuais, hipossuficiente (fls. 135/139).

É o relatório.

DECIDO.

A alegação de inimputabilidade é acolhida como preliminar.

Não houve oportuna provocação para instauração de incidente de dependência toxicológica, com mínima comprovação que fosse a esse respeito.

De outro lado, o réu, interrogado, a tudo respondeu, com coerência, coordenação, em nada demonstrando que por conta de vício tivesse comprometimento de sua higidez mental.

O artigo 45 da Lei de Drogas, ao dispor que “é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”, na lição de Cleber Masson, “Excepcionalmente, entretanto, agasalhou o art. 45 da LD o sistema psicológico – da mesma forma que o art. 28, § 1º, do CP (completa embriaguez accidental ou fortuita) –, em relação ao cometimento do fato sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior. Nesse caso, pouco importa se o indivíduo apresenta ou não alguma dependência química. Será inimputável ao se mostrar incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão da ingestão involuntária do entorpecente, por ignorância (caso fortuito) ou coação (força maior) Lei de Drogas, 2019, fls.169.

Não é, evidentemente, o caso dos autos, como se sublinhou, em que não há qualquer notícia ou comprovação da ingestão involuntária de droga, por ignorância ou coação, antes provado que no local o réu estaria a delinquir, indiferente de também ser usuário de drogas.

Bem por isso, também ainda adotando lição de Cleber Masson, “No que importa a realização de exame de dependência toxicológica, para que o magistrado o determine, deve haver uma dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Ou seja, a autorização para a realização da perícia “deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação”. Lado outro, sendo inconteste que o agente tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu o seu comportamento de acordo com esse entendimento, não há falar em incidente de insanidade, porquanto a mera alegação de dependência de drogas pelo réu “não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado.” -op. citada, fls.171.

Na jurisprudência:

STJ, HC 336.811/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.06.2016.

“No caso dos autos, a instauração do incidente de dependência toxicológica foi indeferida, motivadamente, em virtude de o Juiz ter entendido que 'os réus não apresentavam nenhum indício de que sua capacidade mental estivesse comprometida, em razão do possível uso de substância entorpecente' [...]. Dessarte, não há se falar em cerceamento de defesa.” (HC 310.899/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.06.2016) STF, HC 99.487/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 26.10.2010; HC 114.431/MS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21.05.2013.

“As instâncias ordinárias fundamentaram, concretamente, a desnecessidade de instauração de incidente de dependência toxicológica, tendo salientado, com base em elementos concretos e idôneos dos autos, a ausência de indícios que efetivamente evidenciassem que os agravantes, ao tempo da ação, eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” (STJ, AgRg no AREsp 559.766/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.06.2015).

Vale dizer, a ingestão voluntária ou o consumo deliberado de drogas não tem aptidão alguma para excluir a culpabilidade da conduta.

No mérito, a denúncia é procedente, na íntegra.

O crime está suficientemente demonstrado.

Desde o inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Alegou que estava desempregado. Era amigo de Marta, também usuária de entorpecentes. Estava na Rua Ema, no bairro Jardim dos Lírios, quando a viatura da Guarda Municipal se aproximou. Foi abordado e revistado. Os policiais encontraram no chão, perto do seu pé, seis porções de maconha. Colocou as suas drogas ali quando avistou os guardas. Iria trocar as porções de maconha por pedras de crack.

Tinha um maço de cigarros, onde guardava certa quantia, que não soube precisar. O dinheiro era proveniente da coleta de recicláveis. Em seguida, foi apresentado no plantão policial (fls. 10).

Em Juízo, repetiu a versão: portava droga para usar. Beirava a pista, no bairro Jardim dos Lírios. Fazia uso de drogas. Não se recordava se ganhou ou encontrou a droga, pois estava alcoolizado. Como estava muito ruim, foi embora para a sua casa. Ao sair da pista e acessar o bairro Jardim dos Lírios, foi abordado pelos Guardas Municipais. Estava com a droga que iria usar, que acabou jogando.

A confissão do réu não ficou isolada nos autos.

Agnaudo Augusto Asbahr, guarda municipal, alegou que receberam informação, via controle, de que havia um casal traficando na Rua Ema com a Rua Violetas. Era o motorista da viatura e foram até o endereço informado. No local, avistaram o Rafael e a Marta. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou sair e deixou algo cair.

Realizaram a abordagem. Durante a revista, localizaram seis porções de substâncias, que aparentavam ser maconha. Marta estava perto de Rafael. Ao ser questionada, alegou que não tinha nada em seu poder. Solicitaram a presença de uma Guarda Municipal feminina para revistá-la. Foi encontrada a quantia de R\$ 195,00 na calcinha da Marta. Ela justificou que havia mais uma pessoa, que pediu para que ela segurasse a quantia e deixou o local. Rafael informou para a equipe que havia achado aquela porção de maconha e estava tentando trocar a droga pela substância que usava (crack), porque não era usuário de maconha. Diante dos fatos, apresentaram os envolvidos no Plantão Policial para deliberações da autoridade policial.

Cleiton Marques de Souza, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que ao avistar a viatura, o suspeito virou-se de costas para a equipe e jogou algo no chão. Durante a abordagem, localizaram algumas porções de drogas. Indagado, o réu alegou que achou os entorpecentes (maconha) na rua e tentava trocá-lo por crack. Havia uma mulher em companhia do acusado, que alegou que apenas estava parada no local. Negou que estivessem traficando. Com a parte feminina, encontraram dinheiro. O local era conhecido como ponto de tráfico de drogas, frequentado por vários usuários. Rafael informou para a equipe que estava à procura de crack.

Negou que fosse usuário de maconha, droga encontrada perto dele, possivelmente objeto que o acusado havia jogado.

A testemunha Marta Ferreira da Cruz, ouvida apenas na fase policial, alegou que conhecia Rafael em razão de ambos serem usuários de drogas. Estava no bairro Jardim dos Lírios, onde fazia uso de entorpecentes. Quando parou para conversar com sua amiga Ana Maria, Rafael se aproximou. A viatura também chegou, momento em que Ana Maria entregou uma quantia em suas mãos e disse "segura aí", deixando o local. Foi abordada. Durante a revista, os guardas localizaram dinheiro dentro da sua calça, em sua cintura. Não portava nada de ilícito. Rafael contou que foi até o local para buscar drogas para consumir (fls. 09).

Pelo contexto probatório, há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

A droga apreendida com o réu é indubitosa, não só pela confissão como também pela prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo dela e do numerário com o tráfico, convencem que era mesmo para o uso próprio, ainda subsidiariamente.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para

a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469). Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Aqui, a confissão está em plena harmonia com os depoimentos dos guardas municipais. A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Evidente, assim, que o réu trazia com ele drogas, as quais, pela quantidade, indicavam mesmo se destinar ao consumo, o que se depreende tendo em conta a confissão do réu e a ausência de prova robusta de tráfico, sequer denunciado.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, Resp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, Resp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

A materialidade foi provada pelo exame químico toxicológico.

Fixação das penas.

Na fixação da pena, observo que o réu possui maus antecedentes (Processo nº 3001359-23.2013.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Forum de Americana/SP - Art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/04/2014) e é reincidente (vg. Processo nº 0008210-61.2015.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Forum de Americana/SP - Art. 155, §4º, IV, do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/06/2017), o que interferirá na fixação da pena. É igualmente confesso, atenuante.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28, § 4º da Lei 11.343/2006, intermediário. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Pela reincidência, serão aplicadas prestação de serviços e advertência, pelo prazo de cinco (05) meses, além de comparecimento a cursos (medida socioeducativa) ou programas da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra

RAFAEL BATISTA FARIA, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 96).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 04 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA